TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
45ª VARA CÍVEL CENTRAL DA CAPITAL
PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, 14º ANDAR – SALA Nº 1.425
CENTRO – SÃO PAULO/SP – CEP: 01501-900
TEL.: (11) 2171-6268 UPJ I – *E-MAIL*: UPJ41A45@TJSP.JUS.BR

CONCLUSÃO

Em 23 de junho de 2020, faço conclusão destes autos ao MM. Juiz de Direito, Dr. Guilherme Ferreira da Cruz. Eu, Guilherme Ferreira da Cruz, escrevente técnico judiciário.

SENTENÇA

Processo nº:	**1038416-16.2020.8.26.0100**
Classe - Assunto	**Procedimento Comum Cível - Tratamento médico-hospitalar**
Requerente:	**Tarik Romano Saker Mapelli**
Requerido:	**Sul América Companhia de Seguro Saúde**

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: **Dr. Guilherme Ferreira da Cruz**.

Vistos.

TARIK ROMANO SAKER MAPELLI – que padece de câncer – ajuizou a presente ação de OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. DANOS MORAIS em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, qualificados nos autos, objetivando: a) impor à ré o custeio e o fornecimento da medicação *BENDAMUSTINA*; b) reparar os danos morais que suportou (R$ 20.000,00).

Deferida a tutela provisória (fls. 126/127), sobreveio emenda (fls. 128/142). Citada (fls. 147), ofertou a ré contestação (fls. 148/209).

Argui, preliminarmente, a nulidade de citação. No mérito, sustenta que o tratamento com *BENDAMUSTINA* é *off label*, sequer constando do rol da ANS. Embora *o medicamento BENDAMUSTINA, que possui registro na ANVISA com o nome RIBOMUSTIN, foi negado pois não apresenta na sua bula, indicação de uso para o diagnóstico apresentado pelo autor (sic)*. A negativa de cobertura contratual está correta (*pacta sunt servanda*). Inexistem danos morais. Pede a improcedência.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GUILHERME FERREIRA DA CRUZ, liberado nos autos em 23/06/2020 às 11:29 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1038416-16.2020.8.26.0100 e código exlPLKsa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
45ª VARA CÍVEL CENTRAL DA CAPITAL
PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, 14º ANDAR – SALA Nº 1.425
CENTRO – SÃO PAULO/SP – CEP: 01501-900
TEL.: (11) 2171-6268 UPJ I – *E-MAIL*: UPJ41A45@TJSP.JUS.BR

Houve réplica (fls. 213/219).

É a síntese do necessário.

Fundamento e DECIDO.

A presente ação comporta julgamento antecipado, porquanto a solução da matéria independe de dilação probatória, *ex vi* do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Não vinga a preliminar, pois o ato de chamamento (fls. 147) alcançou o seu desiderato, a prevalecer a instrumentalidade que chancela a teoria da aparência; vício algum, portanto, se identifica a macular o ato de citação.[1]

Quanto ao mérito, a versar a lide sobre a cobertura de planos de saúde, avulta clara como o sol que reluz a incidência – à espécie – da Lei nº 8.078/90[2], sobretudo quanto à vulnerabilidade material e à hipossuficiência processual do consumidor.[3]

Fixadas tais premissas, procede o pedido.

Com efeito, admitida a cobertura para a especialidade *oncologia*, os demais procedimentos adotados a partir daí – no mínimo – representam *patologia de consequência* e também devem ser suportados pela operadora, até porque prescritos por médico (fls. 72/78) – único titular da opção terapêutica – no intuito de recuperar o paciente[4], que foi diagnosticado com *Linfoma não-Hodgkin difuso de grandes células* (CID 10 C859 e C83.3 – fls. 72).

Observe-se, a propósito, que o Excelso Superior Tribunal de Justiça firmou diretriz no sentido de considerar abusiva a cláusula que exclui da cobertura do plano de saúde o custeio de

[1] CPC, arts. 239, § 1º, c.c. 283, par. ún.
[2] STJ, Súm. 608.
[3] CDC, arts. 4º, I, c.c. 6º, VIII.
[4] STJ, REsp. 519.940/SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 17.06.2003.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GUILHERME FERREIRA DA CRUZ, liberado nos autos em 23/06/2020 às 11:29 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1038416-16.2020.8.26.0100 e código exlPLKsa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
45ª VARA CÍVEL CENTRAL DA CAPITAL
PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, 14º ANDAR – SALA Nº 1.425
CENTRO – SÃO PAULO/SP − CEP: 01501-900
TEL.: (11) 2171-6268 UPJ I – *E-MAIL*: UPJ41A45@TJSP.JUS.BR

material/remédio necessário ao pleno restabelecimento do contratante, sendo indiferente se é ele importado ou não.[5]

De igual modo não interessa a circunstância de a medicação − em qualquer dosagem − eventualmente e por força da proporcionalidade, ser experimental (*off-label*[6]) e/ou não estar incluída no rol da ANS[7], diretrizes de utilização da bula inclusive, sobretudo quando há registro na ANVISA (fls. 159) e a prescrição não é desconstituída de modo técnico durante o contraditório.

Além disso, é necessário ter em vista que a um catálogo de natureza administrativa é impossível contemplar todos os avanços da ciência, muito menos esgotar as moléstias e seus meios curativos usados pela comunidade médica com base científica.[8]

Em hipóteses análogas, a cominar a cobertura do mesmo fármaco, assim decidiu a Corte Bandeirante[9]:

> *PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE LINFOMA NÃO HODGKIN FOLICULAR (OBINUTUZUMABE E BENDAMUSTINA). O E. STJ, em regime de recursos repetitivos (REsp 1712163/SP e REsp 1726563/SP), estabeleceu que a negativa de cobertura é lícita apenas para as hipóteses de medicamentos não registrados ou autorizados pela ANVISA: "As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA". Medicamentos prescritos à autora registrados na ANVISA. Limitação de cobertura que não se estende ao medicamento devidamente registrado prescrito ao paciente de forma diversa daquela que consta na bula (off label). Cobertura devida. Ação*

[5] STJ, AgRg no Ag 1.139.871/SC, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 27.04.2010. Em igual sentido e da mesma Corte: REsp. 1.046.355/RJ, rel. Min. Massami Uyeda, j. 15.025.2008.
[6] STJ, REsp 1.769.557/CE, rel. Min, Nancy Andrighi, j. 13.11.2018.
[7] TJSP, Súm. 102.
[8] TJSP, AC 479.806.4/2-00, rel. Francisco Loureiro, j. 01.02.2007.
[9] TJSP, Súms. 95 e 96.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GUILHERME FERREIRA DA CRUZ, liberado nos autos em 23/06/2020 às 11:29 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1038416-16.2020.8.26.0100 e código exlPLKsa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
45ª VARA CÍVEL CENTRAL DA CAPITAL
PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, 14º ANDAR – SALA Nº 1.425
CENTRO – SÃO PAULO/SP − CEP: 01501-900
TEL.: (11) 2171-6268 UPJ I – *E-MAIL*: UPJ41A45@TJSP.JUS.BR

procedente. V. acórdão mantido.[10]

PLANO DE SAÚDE − OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO − AUTOR PORTADOR DE LINFOMA NÃO HODGKIN FOLICULAR − NEGATIVA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO − OBINUTUZUMABE COMBINADO COM BENDAMUSTIN − INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 51, INCISO IV, DA LEI FEDERAL Nº 8.078/90 − ABUSIVIDADE RECONHECIDA − DOENÇA QUE INTEGRA O ROL DE COBERTURAS OBRIGATÓRIAS − FÁMARCOS REGISTRADOS NA ANVISA − PRECEDENTE JULGADO EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO − FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DA DEMANDA NÃO PREJUDICA A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA − ATO ILÍCITO CARACTERIZADO − DANO MORAL QUE EXTRAPOLA A ÓRBITA DO MERO DISSABOR E DECORRE DA PRÓPRIA NATUREZA (VIDA E SAÚDE) − INDENIZAÇÃO FIXADA R$10.000,00 − SENTENÇA REFORMADA − PRETENSÃO TOTALMENTE PROCEDENTE − RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.[11]

Toda a responsabilidade é da operadora, nulas as cláusulas obstativas[12] e abusiva a negativa de cobertura (fls. 82).

Percebe-se, de modo considerável, que a dinâmica dos fatos extrapolou − a partir da acentuada vulnerabilidade daquele que precisa da **urgente** cobertura do seu plano de saúde para lutar contra o câncer (já com recidiva) − o mero inadimplemento, galgando o vício contornos de defeito.

Existência de entendimento pacífico desta Corte Superior no sentido de que a recusa indevida de cobertura de procedimento médico urgente impõe ao usuário de

[10] TJSP, AC 1129224-09.2016.8.26.0100, rel. Mary Grün, j. 25.09.2019.
[11] TJSP, AC 1015287-43.2018.8.26.0361, rel. Erickson Gavazza Marques, j. 14.05.2020.
[12] CDC, art. 51, IV e XV, c.c. seu § 1º, I, II e III.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GUILHERME FERREIRA DA CRUZ, liberado nos autos em 23/06/2020 às 11:29 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1038416-16.2020.8.26.0100 e código exlPLKsa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
45ª VARA CÍVEL CENTRAL DA CAPITAL
PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, 14º ANDAR – SALA Nº 1.425
CENTRO – SÃO PAULO/SP – CEP: 01501-900
TEL.: (11) 2171-6268 UPJ I – *E-MAIL*: UPJ41A45@TJSP.JUS.BR

> *plano de saúde um grau de sofrimento físico/psíquico que extrapola aquele decorrente do mero inadimplemento contratual, atingido direito da personalidade, e dando ensejo a indenização por danos morais.*[13]

Tal ocorre em razão de o intérprete soberano da legislação federal estar cada vez mais flexível e tendente a excepcionar determinadas situações nessa temática (**acórdão deste mês**).[14]

> *Conquanto a jurisprudência do STJ seja no sentido de que o mero inadimplemento contratual não ocasiona danos morais, esse entendimento deve ser excepcionado nas hipóteses em que da própria descrição das circunstâncias que perfazem o ilícito material é possível se verificar consequências de cunho psicológico que são resultado direto do inadimplemento.*[15]
>
> *2. Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os experimentais. Precedentes.*
> *3. A recusa indevida pela operadora do plano de saúde em autorizar a cobertura de tratamento, mesmo nessas hipóteses, é suficiente para gerar dano moral.*[16]

Pensar-se o contrário implicaria direta afronta à função *corrigendi gratia* ou reativa da boa-fé objetiva (vetor do mínimo ético exigível), que visa a impedir comportamentos que contrariem os pressupostos da lealdade e da probidade[17] ou, nas palavras de Menezes Cordeiro, o exercício inadmissível de posições jurídicas.[18]

É dizer: verificada a inexecução obrigacional

---

[13] STJ, AgInt no REsp. 1.869.858/DF, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 15.06.2020.
[14] STJ, REsp. 986.947/RN, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11.03.2008.
[15] STJ, REsp. 1.072.308/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.05.2010. Em igual sentido e da mesma Corte: AgRg no Ag 1010856/RJ, rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, j. 18.11.2010.
[16] STJ, AgInt no AREsp. 1.558.074/RJ, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 15.06.2020.
[17] Judith Martins-Costa. *A boa-fé no direito privado*. 2ª tir. São Paulo: RT, 2000, p. 457.
[18] *Da boa-fé no direito civil*. Coimbra: Almedina, 1984, v. 2, p. 661.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GUILHERME FERREIRA DA CRUZ, liberado nos autos em 23/06/2020 às 11:29 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1038416-16.2020.8.26.0100 e código exlPLKsa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
45ª VARA CÍVEL CENTRAL DA CAPITAL
PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, 14º ANDAR – SALA Nº 1.425
CENTRO – SÃO PAULO/SP – CEP: 01501-900
TEL.: (11) 2171-6268 UPJ I – *E-MAIL*: UPJ41A45@TJSP.JUS.BR

que ultrapassa o limite do aceitável[19], caracteriza-se o ato ilícito diante da ofensa danosa à esfera de dignidade e aos direitos básicos do consumidor, a quem o Estado deve defender[20], reprimindo todos os abusos praticados no mercado[21], tanto que, *a partir da consagração do direito subjetivo constitucional à dignidade, o dano moral deve ser entendido como sua mera violação*.[22]

Não se ponha no oblívio que os direitos da personalidade compõem apenas uma parcela do patrimônio imaterial protegido pelo sistema jurídico, mas não a única.

A classificação do dano unicamente pelo critério da patrimonialidade não alcança o extenso plano dos danos morais; entretanto, analisando-se a matéria com os olhos voltados à defesa do consumidor, mais fácil será o entendimento e a compreensão acerca, *v.g.*, do dever de indenizar pela simples falha do produto ou do serviço fornecidos – sem reflexos patrimoniais diretos nem morais, se considerados *stricto sensu* – ou seja, tão-só pela quebra da expectativa legítima da correção, da qualidade e da segurança oferecidas.

Incide, aqui, a teoria do risco proveito, fundada na livre iniciativa[23], que relega ao empreendedor, de forma exclusiva, o ônus da atividade econômica lucrativa explorada. Ou seja, se os lucros não são divididos com os consumidores, os riscos também não podem ser.

> *A manifestação de vontade do consumidor é dada almejando alcançar determinados fins, determinados interesses legítimos. A ação dos fornecedores, a publicidade, a oferta, o contrato firmado criam no consumidor expectativas, também, legítimas de poder alcançar estes efeitos contratuais.*
>
> *(...)*
>
> *No sistema do CDC leis imperativas irão*

[19] CC, art. 187.
[20] CF, art. 5º, XXXII.
[21] CDC, art. 4º, II e VI.
[22] STJ, REsp. 1.328.916/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 01.04.2014.
[23] CF, arts. 1º, IV, c.c. 170.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GUILHERME FERREIRA DA CRUZ, liberado nos autos em 23/06/2020 às 11:29 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1038416-16.2020.8.26.0100 e código exlPLKsa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
45ª VARA CÍVEL CENTRAL DA CAPITAL
PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, 14º ANDAR – SALA Nº 1.425
CENTRO – SÃO PAULO/SP − CEP: 01501-900
TEL.: (11) 2171-6268 UPJ I – *E-MAIL*: UPJ41A45@TJSP.JUS.BR

> *proteger a confiança que o consumidor depositou no vínculo contratual, mais especificamente na prestação contratual, na sua adequação ao fim que razoavelmente dela se espera, irão proteger também a confiança que o consumidor deposita na segurança do produto ou do serviço colocado no mercado.*[24]

O dever de indenizar, portanto, decorre − de modo imediato (*in re ipsa*)[25] − da quebra da confiança e da justa expectativa do consumidor doente[26], pois *fazer depender a configuração do dano moral de um momento consequencial (dor, sofrimento, etc.), equivale a lançá-lo em um limbo inacessível de sensações pessoais, íntimas e eventuais.*[27]

> *Os princípios da probidade e da confiança são de ordem pública, estando a parte lesada somente obrigada a demonstrar a existência da violação.*[28]

No que tange à liquidação, afigura-se-me razoável − considerando o porte econômico da Sul América e a sua abusiva conduta frente à debilitada saúde do autor doente (fls. 82) − estimar a indenização extrapatrimonial em R$ 10.000,00; contudo, sem nenhum reflexo no princípio da sucumbência, visto que o *quantum* inicialmente proposto (letra "e" − fls. 17) apresenta caráter apenas estimatório.[29]

Tal soma cumpre a função punitiva (intimidativa, pedagógica ou profilática) da indenização, na exata medida do que se conhece como teoria do desestímulo[30], o que é admitido com tranquilidade pela jurisprudência do intérprete soberano

---

[24] Cláudia Lima Marques. *Contratos no Código de Defesa do Consumidor*. 3ª ed. São Paulo: RT, 1999, p. 574.
[25] STJ, REsp. 196.024/MG, rel.Min. César Asfor Rocha, j. 02.03.1999.
[26] CDC, art. 14, *caput*, c.c. seu § 1º.
[27] Anderson Schreiber. *Novos paradigmas da responsabilidade civil. Da erosão dos filtros da reparação à diluição dos danos.* 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 109.
[28] Enunciado 363 da IV Jornada de Direito Civil promovida pelo Conselho da Justiça Federal.
[29] STJ, Súm. 326.
[30] Pedro Frederico Caldas. *Vida Privada, Liberdade de Imprensa e Dano Moral*. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 126.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GUILHERME FERREIRA DA CRUZ, liberado nos autos em 23/06/2020 às 11:29 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1038416-16.2020.8.26.0100 e código exlPLKsa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
45ª VARA CÍVEL CENTRAL DA CAPITAL
PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº, 14º ANDAR – SALA Nº 1.425
CENTRO – SÃO PAULO/SP – CEP: 01501-900
TEL.: (11) 2171-6268 UPJ I – *E-MAIL*: UPJ41A45@TJSP.JUS.BR

da legislação federal.[31]

A correção monetária incide de hoje[32]; enquanto os juros de mora (1% a.m.[33]), tratando-se de responsabilidade contratual[34], fluem – *ex vi legis* – de 25.05.2020 (fls. 147).

O mais não pertine.

Ex positis, e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim de:

a) IMPOR à ré a obrigação de autorizar e custear o tratamento com a droga *BENDAMUSTINA*, de forma contínua e sem interrupções, até orientação contrária do médico assistente; NULAS e ABUSIVAS as cláusulas obstativas;

b) CONDENAR a Sul América Companhia de Seguro Saúde ao pagamento de R$ 10.000,00, corrigidos de hoje e com juros de mora (1% a.m.) de 25.05.2020.

Sucumbente, arca a ré com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor total da condenação líquida (letra "b") ou em R$ 3.000,00, o que for maior.

TORNO, por fim, definitiva a decisão de fls. 126/127.

P. R. I. C.

São Paulo, 23 de junho de 2020.

---

[31] STJ, REsp. 1.171.826/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 17.05.2011.
[32] STJ, Súm. 362.
[33] CC, art. 406 c.c. CTN, art. 161, § 1º.
[34] CC, art. 405.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GUILHERME FERREIRA DA CRUZ, liberado nos autos em 23/06/2020 às 11:29 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1038416-16.2020.8.26.0100 e código exlPLKsa.